

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 04-04-2019
10:06:12

Al Contestar Cite Este Nr 2019EE55548 O 1 Fol 4 Anex 0
Sd 87 - SUBDIRECCIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA/GUZMAN LOZ
ACCOUNTER LTDA/DIANA CAROLINA SARMIENTO VELASQUE
RESPUESTA A RADICADO 2019ER32083 DEL 22/03/2019
MCCA

Bogotá D.C, 4 de abril de 2019

Señores
ACCOUNTER LTDA
Nit. 900 965 093
Att. Diana Carolina Sarmiento Velásquez
Consultor
KR 28 No 46 -97
Tel : 4432300
Bogotá

Referencia : Radicado 2019ER32083 del 22/03/2019
Tema : ICA
Subtema : Territorialidad actividad de servicio (Cloud computing/provider)

Respetada señora Diana Carolina, cordial saludo:

De conformidad con los literales e y f del artículo 31 del Decreto Distrital 601 de 2014, corresponde a esta Subdirección, en ejercicio de la función consultiva, dar respuesta escrita, clara, oportuna y eficaz a las consultas técnico-jurídicas sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias distritales, garantizando la unidad doctrinal y el principio de seguridad jurídica.

En primer lugar, es procedente indicarle que los conceptos emitidos por este Despacho no responden a la solución de casos particulares y concretos, pues estos son discutidos en los procesos de determinación que se adelantan a los contribuyentes, donde se determina de manera particular la situación fiscal real del sujeto pasivo; por consiguiente, bajo estos parámetros se absolverá de manera genérica e impersonal la consulta formulada

CONSULTA

*¿Queremos establecer para efectos de la territorialidad del impuesto de industria y comercio, los servicios de cloud computing (la nube) se entiende sujeto en el lugar de ubicación de los usuarios?
¿O en el sitio donde se encuentran ubicados los servidores y se realiza efectivamente la actividad gravada?*

RESPUESTA

Para dar respuesta a su consulta, nos referimos en primer lugar a los elementos determinantes del Impuesto de Industria y Comercio en el Distrito Capital previstos en el Decreto Distrital 352 de 2002, en su artículo 32 al definir el hecho generador del impuesto de industria y comercio, así:

"Artículo 32. Hecho generador.

El hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos."

De igual manera cabe señalar, la definición de cada una de las actividades económicas descritas en los artículos 33 a 35 del Decreto Distrital 352 de 2002 a saber:

"Artículo 33. Actividad industrial.

Es actividad industrial, la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales y bienes y en general cualquier proceso de transformación por elemental que éste sea.

Artículo 34. Actividad comercial.

Es actividad comercial, la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por menor y las demás actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la ley como actividades industriales o de servicios.

Artículo 35. Actividad de servicio.

Es actividad de servicio, toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual."

Por su parte, los sujetos pasivos del impuesto al tenor de lo señalado en el artículo 41 del Decreto Distrital 352 de 2002, son las personas naturales o jurídicas o las sociedades de hecho, que realicen el hecho generador de la obligación tributaria, consistente en el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital.

Según lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, el nuevo texto transcribe:

"Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto".

Finalmente, la base gravable del impuesto de industria y comercio en la ciudad capital está conformada por:

Artículo 42. Base gravable.

El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada bimestre se liquidará con base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período. Para determinarlos, se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de activos fijos.

Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo (...)

ACTIVIDAD GRAVADA:

Analizados los elementos constitutivos del tributo en el Distrito Capital veremos si la actividad de servicio de Cloud computing se constituye en una actividad gravada con el impuesto de industria y

comercio en Bogotá, para ello, consideramos importante referirnos a la definición de la actividad de computación en la nube o Cloud Computing en los siguientes términos:¹

"La computación en la nube son servidores desde Internet encargados de atender las peticiones en cualquier momento. Se puede tener acceso a su información o servicio, mediante una conexión a internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo(...)"

El Cloud computing es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite incluso al usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder con ellos a las necesidades de su negocio (...)"

También, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en un trabajo conjunto con el MINTIC, expidió el Concepto No. 017056 del 25 de agosto de 2017 en el que se define qué es computación en la nube (cloud computing), cuáles son las características esenciales de este servicio y sus modalidades, al respecto extractamos algunos aspectos relevantes.

"Qué es computación en la nube o (Cloud Computing)?"

Es un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente, y por demanda a una red de un conjunto compartido de recursos computacionales configurables (por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente como un mínimo de esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicios².

2. ¿Cuáles son las características esenciales de la Computación en la nube?

La computación en la nube se compone de las siguientes cinco características primordiales, según Oficio de Registro No. 1058335 del 22 de junio del 2017, expedido por el-MINTIC-:

1. Autoservicio bajo demanda (On- demand selfservice) - Un consumidor puede unilateralmente proveer capacidades de computación, tales como tiempo de servidor y almacenamiento en red, según sea necesario o automáticamente, sin necesidad de interacción humana con cada proveedor de servicios.

2. Acceso amplio a la red (Broad networkAccess- Los servicios proporcionados deben poder ser accesibles a través de mecanismos estándares y desde plataformas heterogéneas (por ejemplo: ordenadores, teléfonos móviles o tabletas)

3. Asignación común de recursos (Resource pooling)- Los recursos son puestos a disposición de los consumidores siguiendo un modelo de multipropiedad, asignándose y reasignándose dispositivos físicos o lógicos atendiendo a la demanda de dichos consumidores. En ese sentido el usuario no tiene un estricto control del lugar exacto en el que se encuentra su información, aunque si debe poder especificar un ámbito mínimo de actuación (por ejemplo: un país o centro de proceso de datos concreto)

4. Rápida elasticidad (Rapid elasticity) -Las capacidades en los recursos proporcionados a los usuarios deben poder crecer o decrecer bajo demanda de los mismos con celeridad, incluso mediante procesos automáticos.

5. Servicio medible (Measured service) - Los sistemas Cloud deben controlar y optimizar sus recursos dotándose de capacidades para medir su rendimiento en un nivel de abstracción suficiente para la naturaleza del servicio proporcionado. Además, dicho control debe permitir ser reportado de manera transparente tanto al proveedor del servicio como al consumidor del mismo."

A modo de conclusión y en virtud de lo transcrito en líneas previas, es palmario que para la prestación de un servicio de computación en la nube (Cloud Computing) se requiere del cumplimiento de las características esenciales, los modelos de servicio a través de uno de los modelos de implementación y los demás que para

¹ Wikipedia

² El Departamento de Comercio de los Estados Unidos a través de su Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, de ahora en adelante) en su publicación especial 800-145

tos efectos determine el MINTIC. Si el servicio no cumple con los elementos necesarios para identificar plenamente el servicio de computación en la nube mencionados en los numerales 1 al 4, no opera la exclusión prevista en el numeral 24 del artículo 476 del Estatuto Tributario."

Ahora bien, como se puede observar la computación en la nube o *cloud computing* "Es un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente, y por demanda a una red de un conjunto compartido de recursos computacionales configurables (por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente como un mínimo de esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicios" (Subrayado y negrita fuera de texto)

Por su parte, el Concepto 0820 del 25 de agosto de 2017 emitido por la DIAN, definen además a los proveedores de la nube como:

"Proveedor de nube (Cloud provider): Persona o entidad responsable de poner a disposición un servicio a las partes interesadas y que gestiona la infraestructura informática necesaria para proporcionar los servicios, ejecuta el software en la nube que proporciona los servicios y entrega los servicios en la nube a los consumidores de nube a través del acceso a la red."

De acuerdo con las definiciones anteriormente señaladas, es de interés citar algunos de los aspectos planteados en la Exposición de Motivos de la Ley 1819 de 2016 sobre el tema, la cual recalcó la intención de gravar aquellos elementos que componen los nuevos avances en materia de tecnología y comunicación, dada su inmensa irrupción en el diario vivir, partiendo de sus beneficios y llegando a la falta de regulación que les permitía convertirse en vehículos aptos para sobrepasar los límites de la normatividad, en este caso la normatividad tributaria, que hasta entonces, no hallaba mecanismos suficientes para obtener recursos por el ejercicio y disposición de esta tecnología.

Sobre el particular, la Exposición de Motivos de la Ley 1819, señaló:

"Prestaciones de servicios y regulación de nuevas TIC: en lo atinente a la modificación del literal b) del artículo (420) se introduce la aplicación del principio de destino (vigente hoy en día para las ventas de mercancía) en las prestaciones de servicios desde el exterior, entendiendo que estas se encuentran sujetas a imposición cuando el destinatario y el usuario del servicio se encuentre localizado en el territorio nacional.

La aplicación del principio de destino en los servicios es una adecuación de la norma fiscal a nuevos fenómenos que se encontraban ajenos a la imposición del Impuesto, entre otros, a aquellos asociados al fenómeno de la economía digital que implica el reconocimiento de los avances de las TIC - tecnologías de la información y la comunicación - que han generado nuevas formas de prestaciones de servicios y generaciones de valor.

Al respecto la OCDE ha manifestado lo siguiente: "La economía digital es el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La revolución de las TIC ha abaratado y potenciado las tecnologías, al tiempo que las ha estandarizado ampliamente, mejorando así los procesos comerciales e impulsando la innovación en todos los sectores de la economía.

Por ejemplo, los minoristas ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar pedidos en línea, pudiendo recabar y analizar los datos relativos a cada cliente para poder ofrecer publicidad a medida y prestar un servicio personalizado; el sector de la logística se ha visto transformado por la capacidad de rastrear y hacer un seguimiento de vehículos y

mercancías a lo largo y ancho del globo; los proveedores de servicios financieros facilitan cada vez en mayor medida a los clientes la gestión de sus finanzas, la realización de transacciones y el acceso a nuevos productos en línea; en el sector productivo, la economía digital ha mejorado la capacidad de supervisar a distancia los procesos productivos y de controlar y utilizar la maquinaria; en el marco del sector educativo, universidades y proveedores de servicios de tutoría y otros servicios educativos son capaces de ofrecer cursos a distancia, lo que les permite familiarizarse con y responder a la demanda global; en el sector sanitario, la economía digital permite hacer un tele diagnóstico y utilizar historias clínicas para mejorar la eficacia del sistema y la experiencia del paciente.

Por último, el sector de los medios de comunicación y radiodifusión ha experimentado una auténtica revolución, viéndose ampliado el papel de las fuentes de información no tradicionales en los medios actuales e incrementada la participación de los usuarios en los medios sirviéndose de las redes sociales y de contenidos generados por los propios usuarios (CGU).

Dado que la economía digital se está convirtiendo cada día más en la economía propiamente dicha, resultaría una tarea ardua, si no imposible, tener que delimitar y separar el radio de acción de la economía digital del resto de la economía a efectos fiscales⁹⁴.

Así las cosas, con la inclusión de este supuesto se pretenden abarcar estas nuevas formas de economía que por el momento son ajenas a supuestos de tributación, tales como "Suministro de páginas web, hosting, almacenamiento en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos, Suministro de software y sus actualizaciones, Suministro electrónico de imágenes, texto y otro tipo de información, así como la disponibilidad de acceso a bases de datos digitales, Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento, Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia Suministro de otros servicios online (publicidad, plataformas participativas, plataformas de pagos, entre otros)."

Finalmente, y a efectos de determinar la territorialidad del impuesto cuando se trata de venta de bienes incorpóreos o prestación de servicios desde el exterior se establecen una regla general en parágrafo 3 en donde se indica que toda prestación de servicios o adquisición de incorpóreos se entiende prestado o adquirido en Colombia cuando el usuario directo o el destinatario tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la sede de su actividad económica en el territorio nacional " (negrilla fuera de texto)

Al respecto de esta actividad, cabe traer a colación el concepto de "**servicio**" dado en términos de la "**prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales**"⁹⁵. La acción de suministrar intangibles o inmateralidades se concreta en un hacer, y de la misma manera es elemento fundamental en la definición de actividad de servicio ya mencionada. Por su parte, el "**hacer**" como concepto, hace referencia al "**ejecutar, poner por obra**

⁹⁴Real Academia Española. Diccionario de la Lengua española, vigésima segunda edición, consulta web del 20121119 a <http://lema.rae.es/drae/?val=servicio>

una acción o trabajo"⁴, en tanto que como obligación es "la que impone realizar un acto o prestar algún servicio"⁵

Así las cosas, para determinar una actividad como de servicio se requiere identificar si el proceso o grupo de operaciones es de suministro de intangibles o inmaterialidades que se concreta en una obligación de hacer, mediante toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie, sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual

En efecto y atendiendo a los conceptos antes planteados, es claro que, dada la naturaleza de la actividad de (Cloud computing) la misma, es considerada como un servicio propio de las TIC, que de acuerdo con la normatividad regulatoria del impuesto de industria y comercio en los términos del citado artículo 35° del Decreto 352 de 2002 resulta gravada con este tributo en el Distrito Capital.

TERRITORIALIDAD DEL SERVICIO:

El análisis del tema de la territorialidad del impuesto de industria y comercio en el ejercicio de la actividad de servicios en otras jurisdicciones requiere examinar los elementos que configuran el hecho generador del tributo y el ejercicio de la actividad gravada, lo cual se encuentra determinado en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, compilado como artículo 195 del Decreto No. 1333 de 1986:

"Artículo 32°. El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejercen o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos." La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-21 de 2006, declaró EXEQUIBLE el texto subrayado contenido en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y compilado en el artículo 195 del Decreto No. 1333 de 1986.

Bajo este contexto, el legislador fijó las reglas de territorialidad del impuesto de Industria y Comercio en el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016⁶, y en particular en el numeral 3°, cuando se trata de la actividad de prestación de servicios a fin de establecer la jurisdicción en la que se deberá tributar:

"Artículo 343. Territorialidad del Impuesto de Industria y Comercio. El impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas:

(...)

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos (negrilla fuera de texto)

a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona;

⁴ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua española, vigésima segunda edición, consulta web del 20121119 a <http://lema.rae.es/drae/?val=hacer>

⁵ Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Guatemala, 1ª Edición Electrónica

⁶ Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones."



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

b) En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato;

c) En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización. Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos discriminados por cada municipio o distrito, conforme la regla aquí establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de municipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. Lo previsto en este literal entrará en vigencia a partir del 1o de enero de 2018.

En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el impuesto se causa a favor del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la tarifa de la actividad ejercida."

CONCLUSIÓN:

Para efecto de establecer la jurisdicción en la cual se genera el tributo se debe determinar el lugar o jurisdicción en la cual se manifiesta la realización del hecho imponible, que para efecto del impuesto de industria y comercio en la actividad de servicio es el lugar donde se lleva a cabo, ejecuta o realiza efectivamente la actividad, independientemente del domicilio social principal de donde se suscriba el contrato, se facture o se despachen los suministros.

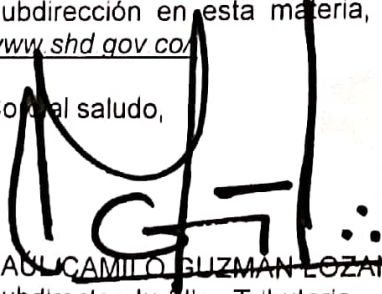
Tratándose de la actividad de servicio de cloud computing, la obligación de tributar surge en la jurisdicción donde se ejecute la prestación del servicio, es decir, en el lugar donde se entienda que realizan los actos propios de la consumación del servicio, como lo es, el uso de los servidores, contraseñas, usuarios y el acceso a las bases de datos de las que dispone el solicitante; situación que debe determinar el propio contribuyente para poder dar estricto cumplimiento a su responsabilidad.

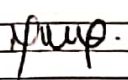
En el desarrollo de la actividad de servicio in examine se dará aplicación a los preceptos contenidos el numeral 3° del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 antes citado.

Finalmente, sobre las actividades desarrolladas en otras jurisdicciones, será en éstas, donde le asiste el deber de presentar y pagar las correspondientes declaraciones.

En los anteriores términos esperamos haber resuelto sus inquietudes y cordialmente le informamos que tanto la normativa y jurisprudencia tributaria, así como los conceptos emitidos por esta Subdirección en esta materia, pueden consultarse directamente en nuestra página web <http://www.shd.gov.co>

Cordial saludo,


SAÚL CAMILO GUZMÁN LOZANO
Subdirector Jurídico Tributario

Revisado por	Saúl Camilo Guzmán Lozano		02/04/2019
Proyectado por	María Cristina Cárdenas Acosta		02/04/2019
Reporte 095/19 - 2019ER32083			

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
P.O. Box 15711 338 5000
Información Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
contactenos@shd.gov.co
Tel. 899 999 061-9
Bogotá Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

28-F.02
V.8